

1506445-86.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... sangue de seu nariz. Ali há um portão. O tráfico é fora da casa; ali dentro moram trabalhadores. Não é verdadeira a alegação de que o tráfico fica dentro do portão. Antes os traficantes ficavam dentro do quintal, pois não tinha portão, mas agora não. E há uma mensagem, manter portão fechado. Na verdade, a abordagem foi na rua Oito, 34, Jardim Nossa Senhora Aparecida. Houve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1506445-86.2022.8.26.0228 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 19 de abril de 2022, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito o(a) Dr(a). FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1506445-86.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

KENNEDY EDUARDO LIMA NASCIMENTO

Vistos.

KENNEDY EDUARDO LIMA NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, em 17 de março de 2022, por volta das 12h20, na avenida Elísio Teixeira Leite, 7.000, Jaraguá, nesta Capital, tinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 467 porções de cocaína, pesando 201,6 gramas, e 35 porções de maconha, pesando 55,7 gramas, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida e a defesa preliminar foi apresentada.

Durante a instrução, foram juntados documentos, como auto de exibição e apreensão de 35 porções de maconha e 467 porções de cocaína (fls. 14); auto de constatação das substâncias tetrahydrocannabinol e cocaína (fls. 18/20); e laudo de exame químico-toxicológico, em que se atestou tratar de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no país (fls. 72/74); bem como foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (audiovisual).

Memoriais (fls. 93/106 e 111/117).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é improcedente.

Dos elementos de prova coligidos aos autos, verifica-se que não é hábil para embasar a condenação, pois está eivado de vício insanável. Vislumbra-se pela prova

colhida em juízo que os policiais ingressaram na residência do réu sem o respectivo mandado de busca e apreensão e sem qualquer autorização, resultando em prova ilícita.

Vejamos a prova oral.

O policial militar Vagner de Matos Santos falou que houve disque denúncia e foram averiguar o local conhecido como de tráfico. Ali identificaram o portão aberto, onde moram várias pessoas. Identificaram-se e o réu apareceu. Disseram a situação e ele autorizou a entrada na residência. Ele parecia ter usado drogas. Próximo ao sofá havia caixa com drogas. O réu negou ser dele. Deram voz de prisão. Houve resistência. No DP, informalmente, o réu falou ser sua a droga e que era o gerente, sendo que ganhava R\$5.000,00. Tinha filmagem, mas quem gravou foi a do outro policial, pois a câmera do depoente caiu no deslocamento. Não tem a filmagem do colega. Era uma habitação coletiva; um portão, uma casa debaixo, uma casa de cima e uma viela onde moradores passam para sair na outra rua. O disque denúncia especifica que o tráfico acontecia e moradores não tinham paz. Entraram na casa debaixo, em que a porta estava meio aberta. Só o réu e dois policiais estavam na casa. Na casa de cima havia outras pessoas, talvez parentes. Só entraram na cozinha e sala, não prosseguindo no restante. A caixa com drogas estava no chão ao lado do sofá. Havia maconha, cocaína, pedra. Não se recorda da quantidade. Nessa ocorrência, participaram os dois policiais e pediram apoio da Rocam, que conteve pessoal que fazia barulho na ocorrência. A câmera do outro policial foi tirada em pequena luta corporal com o réu, mas as imagens são salvas. Estavam de Rocam e caiu, por isso perdeu a câmera. Havia familiares do réu.

O policial militar Roger Oliveira Zanardi asseverou que houve denúncia por meio do disque denúncia do 18º Batalhão. Moradores da região informaram que próximo a uma viela, com um portão, uma casa era usada para guarda de drogas comercializadas perto. Junto com o colega foram ao local e havia um dos informantes, morador. Adentraram a viela e chamaram na casa informada, saindo o réu, noticiando a denúncia. Pediram o ingresso e foi autorizado. Na casa localizaram caixa de sapatos com drogas. O réu foi questionado e negou ser dele. Houve resistência do réu, o qual foi contido e algemado. No DP, ele informalmente confessou ser o gerente do tráfico da região. A autorização do réu foi filmada pela câmera do depoente, pois estava na frente. Ali é um grande terreno com várias casas, sendo que no quintal havia familiares do réu, irmãs, primas e outros moradores. A casa era pequena, uma sala, quarto, cozinha e banheiro. Adentraram com ele e revistaram, sendo que próximo do sofá estava a caixa. Ele pegou e abriu, onde havia porções de maconha, crack e cocaína. Pediram apoio, no momento de resistência do réu. A caixa estava no chão ao lado do sofá.

O interrogatório do réu Kennedy Eduardo Lima Nascimento: em sede policial, confessou a prática delitativa, alegando que não permitiu a entrada dos policiais em sua residência (fls. 09). Em juízo, ele disse ter 25 anos, morar com a mãe, esposa e irmãos, trabalhar em transportadora, como ajudante de caminhão, já ter sido processado por tráfico, ter estudado até oitavo ano. Nega os fatos. Estava voltando da padaria e dois policiais civis abordaram um traficante no ponto de drogas. Foi abordado e perguntaram se tinha passagens, informou e eles o ameaçaram, pediram dinheiro e arma. Chamou sua irmã, que mora na parte de cima da outra casa. Ao descer, os policiais o colocaram dentro da casa, pegaram a caixa, liberaram aquela pessoa e o levaram à delegacia. Os dois policiais civis foram embora e chegaram esses dois PMs, sendo que houve também arrombamento da porta. Foi ferido no pescoço de tanto que o enformaram, os PMs, tiraram sangue de seu nariz. Ali há um portão. O tráfico é fora da casa; ali dentro moram trabalhadores. Não é verdadeira a alegação de que o tráfico fica dentro do portão. Antes os traficantes ficavam dentro do quintal, pois não tinha portão, mas agora não. E há uma mensagem, manter portão fechado. Na verdade, a abordagem foi na rua Oito, 34, Jardim Nossa Senhora Aparecida. Houve invasão de domicílio. Sua irmã e cunhada estavam lá.

Vale ainda notar que juntadas as imagens das câmeras acopladas ao uniforme dos policiais, confirmou-se o ingresso na residência sem autorização. Pelas filmagens é possível visualizar que quando os policiais adentraram a casa, já havia dois outros em seu interior e nada há a comprovar a alegada autorização por parte do morador.

Turmas penais unificam orientação sobre prova de autorização do morador para a entrada da polícia. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base no precedente firmado pela Sexta Turma no HC 598.051, ratificou o entendimento de que cabe ao Estado demonstrar, de modo inequívoco – inclusive por meio de registro escrito e de gravação audiovisual –, o consentimento expresso do morador para a entrada da polícia em sua casa, quando não houver mandado judicial. (Processo nº HC 616.584).

Os Tribunais Superiores tem enfrentado a questão reiteradamente:

Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem autorização judicial. Necessidade de autorização escrita ou gravada do morador de modo a não ficar dúvida sobre o seu consentimento. (AgRg no REsp 1.865.363 – SP. Antonio Saldanha Palheiro. j. 22/06/2021. 6ª T; HC 616.584 – RS. Ribeiro Dantas. j. 30/03/2021. 5ª T; HC 598.051 – SP. Rogério Schietti Cruz. j. 02/03/2021. 6ª T).

Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem autorização judicial. Demonstração de nervosismo NÃO AUTORIZA a abordagem nem a entrada em residência sem o consentimento do morador. Constrangimento ilegal evidenciado. (HC 659.689 – DF. Sebastião Reis Junior. j. 15/06/2021. 6ª T; HC 658.403 – SP. Rogerio Schietti Cruz. j. 25/05/2021).

Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem autorização judicial. Ingresso forçado e sem justa causa em residência. IMPOSSIBILIDADE. Nulidade das provas obtidas por meio da medida de busca e apreensão ilegal. Constrangimento ilegal evidenciado. (HC 608.286 – PR. Joel Ilan Paciornik. j. 27/05/2021).

Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem autorização judicial. Ingresso baseado em mera avaliação subjetiva dos policiais. IMPOSSIBILIDADE. Nulidade das provas obtidas por meio da medida de busca e apreensão ilegal. Constrangimento ilegal evidenciado. (HC 657.997 – SP. João Otávio de Noronha. j. 21/05/2021).

Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem autorização judicial. Se houver autorização de parente hospedado no local e elementos suficientes da prática de crime permanente É LEGÍTIMA E VÁLIDA A ENTRADA de policiais em domicílio particular. (RHC 141.544 – PR. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 15/06/2021. 5ª T). Contudo, segundo a dinâmica dos fatos narrada, apenas após entrar na residência é que se descobriu a existência de entorpecentes. Ou seja, a entrada no domicílio não foi motivada pela suspeita da prática de crime permanente, que só foi descoberto após o ingresso. É bem verdade que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes, o estado de flagrância protraí-se no tempo; contudo, isso não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. Consoante julgamento do RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. Entretanto, extrai-se do contexto fático delineado no aresto a inexistência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo em vista que os policiais se encontravam em patrulhamento de rotina e não realizaram diligências prévias com vista a esclarecer os fatos. Soma-se a isso a inexistência de prova do consentimento para ingresso dos policiais no domicílio, o que, consoante recente entendimento jurisprudencial desta Corte, se faz imprescindível. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELO MORADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme mais recente orientação jurisprudencial, traduzida em novel julgado da Sexta Turma (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021), o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. Ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). No mesmo sentido: HC

616.584/RS, Rel. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe 6/4/2021. 2. Na hipótese, embora os policiais afirmem que a entrada no imóvel foi autorizada pela moradora, a defesa técnica nega essa versão. Assim, na ausência de provas de que o consentimento foi livremente prestado, é caso de reconhecimento da ilegalidade, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar e todas aquelas dela decorrentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1729469/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)" (EDcl no HABEAS CORPUS Nº 685978 - SP (2021/0254047-0), relator : MINISTRO OLINDO MENEZES, j. 01/02/2022).

De tal modo, resta comprovado que os policiais militares ingressaram na residência do réu sem sua autorização e sem mandado judicial, em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Ora, a Constituição Federal estabelece um rol de direitos individuais e dá especial proteção para a inviolabilidade do domicílio, em seu artigo 5º, inciso XI: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. E, nestes termos, limita de modo significativo os casos de restrição a essa inviolabilidade.

No caso, os agentes públicos ofenderam tal direito, pois ingressaram na casa sem autorização do dono, sem autorização judicial, além de não atuarem nas formas excepcionais previstas nas Constituições. A inobservância do regramento constitucional, por consequência, torna imprestável os atos realizados e, ainda, contamina todos os demais que dela se originaram. E não há como compatibilizar a conduta dos policiais com a exceção de ingresso em razão de flagrante delito, sob o argumento de que se trata de crime permanente, pois para isso é necessário que os agentes tenham ciência do estado de flagrância – o que não ocorreu no caso vertente. Não basta que seja algo hipotético – oriundo de denúncia anônima; exige-se que exista uma circunstância real que leve os agentes a concluir pela existência do estado flagrancial de determinado crime, antes do ingresso na residência.

Pelas narrativas dos policiais, nota-se que eles não sabiam que estavam diante de uma situação real de flagrante. O que eles relataram foi que havia denúncia anônima de que naquele local era praticado o tráfico de drogas. Isso não traz informação alguma sobre a prática de determinado delito, até porque não houve investigação nem campana. A invasão não pode ser justificada a posteriori (com o alegado encontro das drogas), mormente no caso concreto, em que havia notícia anterior da ocorrência de tráfico no local e que não ensejou investigação pela polícia judiciária competente para isso e o pertinente mandado de busca domiciliar – quando isso era perfeitamente possível de se fazer.

Ora, se havia notícias anteriores da prática delitiva na casa do réu deveriam os policiais comunicar à autoridade policial para formalizar a investigação, por meio de inquérito policial, e essa, seguindo os ditames legais, comunicar o Ministério Público e representar à autoridade judicial pela autorização de ingresso na residência. Contudo, nada disso foi feito.

É certo que o domicílio não pode servir de porto seguro para a prática de delitos e é por isso que a Constituição da República prevê os casos em que é possível adentrá-la. Contudo, o Estado não praticar ilicitudes no combate ao crime. A exceção constitucional deve ser transportada para o mundo real, para a situação fática que revele concretamente, de maneira específica, o estado de flagrante, não se permitindo suposições nem interpretações ampliativas. Se dispensado isso, ou seja, se bastasse afirmar que o crime de tráfico é permanente para autorizar a polícia a entrar em qualquer residência, ninguém estaria a salvo do Estado e se estaria anulando a exceção constitucional. E não há que se olvidar que se os policiais adentrassem a casa e nada encontrassem, eles é que estariam incorrendo em ato ilícito.

Portanto, a prova produzida neste processo tem origem em ato que não cumpriu os ditames normativos e que, portanto, é ilícita. Todas as provas, oral ou pericial, derivaram da diligência dos policiais, que nitidamente feriu as normas constitucionais. Assim, elas, por origem ou derivação, devem ser afastadas, sendo forçoso concluir pela inexistência de elementos para confirmar a existência dos

fatos delitivos.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal: PROVA PENAL. BANIMENTO CONSTITUCIONAL DAS PROVAS ILÍCITAS (CF, ART. 5, LVI) - ILICITUDE (ORIGINÁRIA E POR DERIVAÇÃO) - INADMISSIBILIDADE - BUSCA E APREENSÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REALIZADA, SEM MANDADO JUDICIAL, EM QUARTO DE HOTEL AINDA OCUPADO - IMPOSSIBILIDADE (...) GARANTIA QUE TRADUZ LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DO ESTADO EM TEMA DE PERSECUÇÃO PENAL, MESMO EM SUA FASE PRÉ- PROCESSUAL (...) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE PROVA OBTIDA COM TRANSGRESSÃO À GARANTIA DA INVIOABILIDADE DOMICILIAR - PROVA ILÍCITA - INIDONEIDADE JURÍDICA - RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. BUSCA E APREENSÃO EM APOSENTOS OCUPADOS DE HABITAÇÃO COLETIVA (COMO QUARTOS DE HOTEL) - SUBSUNÇÃO DESSE ESPAÇO PRIVADO, DESDE QUE OCUPADO, AO CONCEITO DE "CASA" - CONSEQÜENTE NECESSIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE MANDADO JUDICIAL, RESSALVADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. (...) Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional (art. 5o, XI), nenhum agente público poderá, contra a vontade de quem de direito ("invito domino"), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em aposento ocupado de habitação coletiva, sob pena de a prova resultante dessa diligência de busca e apreensão reputar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude originária. Doutrina. Precedentes (STF). ILICITUDE DA PROVA INADMISSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO (OU PERANTE QUALQUER INSTÂNCIA DE PODER) - INIDONEIDADE JURÍDICA DA PROVA RESULTANTE DA TRANSGRESSÃO ESTATAL AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. - A ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do "due process of law", que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo. - A Constituição da República, em norma revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 5o, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas (CF, art. 1o), qualquer prova cuja obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de violação do direito material (ou, até mesmo, do direito processual), não prevalecendo, em conseqüência, no ordenamento normativo brasileiro, em matéria de atividade probatória, a fórmula autoritária do "male captum, bene retentum". Doutrina. Precedentes. A QUESTÃO DA DOUTRINA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA ("FRUITS OF THE POISONOUS TREE"): A QUESTÃO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. - Ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base, unicamente, em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido, de modo válido, em momento subsequente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária. - A exclusão da prova originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivação - representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do "due process of law" e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal. Doutrina. Precedentes. - A doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos "frutos da árvore envenenada") repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal. Hipótese em que os novos dados probatórios somente foram conhecidos, pelo Poder Público, em razão de anterior transgressão praticada, originariamente, pelos agentes da persecução penal, que desrespeitaram a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. - Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos da persecução penal somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, por agentes estatais, de direitos e garantias constitucionais e legais, cuja

eficácia condicionante, no plano do ordenamento positivo brasileiro, traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos. - Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova - que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal -, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária. - A QUESTÃO DA FONTE AUTÔNOMA DE PROVA ("AN INDEPENDENT SOURCE") E SUA DESVINCULAÇÃO CAUSAL DA PROVA ILICITAMENTE OBTIDA - DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - JURISPRUDÊNCIA COMPARADA (A EXPERIÊNCIA DA SUPREMA CORTE AMERICANA): CASOS "SILVERTHORNE LUMBER CO. V. UNITED STATES (1920); SEGURA V. UNITED STATES (1984); NIX V. WILLIAMS (1984); MURRAY V. UNITED STATES (1988)", v.g. [...] (Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus 90.376-2, Relator: Ministro Celso de Mello).

Destarte, necessário o reconhecimento da invalidade da diligência policial que deu origem a este processo, tendo em vista que violou os ditames constitucionais e, conseqüentemente, tal prova, assim como toda prova dela derivada são inválidas e ineficazes para comprovar a existência do crime imputado ao réu na denúncia. Diante do exposto, ABSOLVO o réu KENNEDY EDUARDO LIMA NASCIMENTO da imputação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos termos do disposto no artigo 386, II, do CPP.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, façam-se as comunicações; atualize-se o histórico de partes; archive-se; oficie-se requisitando a incineração do entorpecente apreendido e das amostras guardadas para contraprova, nos termos do Provimento CSM 2482/2018. Expeça-se alvará de soltura.

São Paulo, 19 de abril de 2022.

FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito